

1501251-19.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501251-19.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501251-19.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TIAGO ELEUZES FAGUNDES DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

TIAGO ELEUZES FAGUNDES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, porque no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 19h25min, no cruzamento da Avenida Domingos Falavina com a Rua Nelson Bruno Nardu; e na Avenida Careal Pedro Maffi, 1.492, nesta cidade e comarca, trazia com ele, transportava e mantinha em depósito, para futura entrega a terceiros, cinquenta e uma porções de "maconha", pesando 21760g, e outras dezoito porções maiores de "maconha", pesando 8450g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portava, ainda, o réu, três balanças de precisão, embalagens plásticas, uma faca, duas tesouras, um rolo de plástico filme, um rolo de sacos plásticos, cinco rolos "durex", uma folha com anotações de contabilidade, um aparelho celular, um baú de motocicleta, duas máscaras e R\$ 49,00.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, perseguiram e detiveram o réu, pois tentou fugir na condução de uma motocicleta ao perceber a viatura,

localizando-se, nas vestes, o dinheiro e o celular, bem como, em um baú acoplado ao veículo, dois tijolos de "maconha".

No imóvel, encontraram os agentes, em diversos cômodos, o restante do entorpecente e os petrechos.

Oferecida a denúncia foi o acusado notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia foi o réu citado e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi o réu interrogado.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão da autoria, aplicando-se a pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante ao estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização, do réu e da esposa, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, que revela o encontro dos entorpecentes, das balanças, das embalagens plásticas, da faca, das tesouras, dos rolos de plástico filme, dos rolos de fita adesiva, da folha com anotações, das máscaras, do baú, do celular, da motocicleta e do dinheiro em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 18/20 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 148/153, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol - THC a substância encontrada.

A perícia efetivada nos petrechos apontou resquícios de "maconha" nas balanças, nas embalagens plásticas, na faca, nas tesouras, nos rolos de plástico filme e nos rolos de fita adesiva (fls. 230/234).

Na fase policial limitou-se o réu a admitir a prática do comércio ilícito.

Em Juízo, explicou o réu ter recebido a "maconha", guardado parte na residência, e estar em transporte do produto ilícito quando abordado por agentes, sendo que por aquela entrega receberia R\$ 400,00.

A confissão quanto à autoria foi revestida de caráter absoluto ante a fala dos agentes.

Vejam os.

Relatam os agentes a perseguição e a detenção ao réu, pois tentou fugir na condução da motocicleta ao notar a viatura, encontrando-se, em revista pessoal, o dinheiro e o celular, além de, no baú, duas porções de "maconha". Detalharam ter o denunciado indicado a existência de drogas no imóvel, onde, após terem a entrada franqueada, encontraram, em diversos cômodos, o restante da substância e os petrechos.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais militares incriminar o réu ou forjar o crime, até porque, trata-se de pessoa desconhecida.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação, guarda ou transporte dos produtos, medida impositiva, na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as

circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). Eventual dificuldade financeira, apontada pelo réu, não autorizaria, de forma alguma, a prática criminosa. Até porque, se assim não fosse, desnecessária seria a existência de normas legais, reguladoras do comportamento humano. Por fim, vale observar que as finalidades da agravante prevista no art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, são a proteção da sociedade, bem como punição mais rigorosa da conduta de quem, valendo-se das facilidades do contexto calamitoso, pratica delitos. In casu, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta do réu, é de rigor o afastamento da mencionada agravante. Nesse sentido: "Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19." (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Andrade Sampaio, 12.02.2021).

Convencida da responsabilidade penal do réu passo a individualizar as penas. Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ante a elevada quantidade de entorpecente encontrado. Verificada a reincidência (fls. 238/263), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de

prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Neste sentido: "(...) Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes." (STJ, HC 671329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 15.06.2021)

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno TIAGO ELEUZES FAGUNDES DE ARAUJO, R.G. n.º 35.163.361, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá apelar o réu desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO dos petrechos e da motocicleta, porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro e do celular (fls. 14/16), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA